

## 포괄임금계약의 유효요건에 관한 고찰 - ‘대법원 판례의 변화추이’를 중심으로 -

성 대 규\*

### <국문초록>

‘포괄임금제 또는 포괄임금계약’은 근로기준법 등 노동관계법령에서 정하고 있는 제도가 아니다. 법원이 대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결을 통해 사업장에서 관행적으로 이루어지던 임금지급 방식의 유효성을 처음으로 인정한 후, 판례에 의해서 발전되어 온 제도이다. 그러나 그 이후 포괄임금제는 지속적으로 비판의 대상이 되어왔다. 우리 판례도 포괄임금제에 대한 비판적 시각을 반영하는 듯 포괄임금제의 유효성에 대하여 지속적으로 보다 엄격하고 제한적인 접근을 해온 것으로 파악된다.

판례는 포괄임금제 방식으로서 정액급제와 정액수당제 방식의 유효성을 인정하고 있다. 그리고 포괄임금계약의 유효요건으로서 당사자의 합의를 최우선적으로 요구하며, 그 외의 요건과 관련해서는 최초 판례부터 오늘날까지 계속해서 엄격성을 강화해 온 것으로 파악된다. 최근의 판례 경향은 무엇보다 ‘근로시간 산정의 어려움 요건’을 중핵적 판단기준으로 하여 포괄임금계약의 유효성 여부가 판단되고 있다. 한편, 판례와 달리, 포괄임금계약에 관한 현재 개정안들은 정액급제와 정액수당제의 포괄임금계약을 전면적으로 금지하는 내용을 담고 있다. 그리고 포괄임금제 방식으로 이해되는 임금지급 사례가 해외에서도 운영되고 있음을 확인할 수 있다.

요컨대 개정안과 같이 포괄임금계약을 전면적으로 금지하는 것만이 정당한 것인지에 대해서는 의문이 없지 않다. 왜냐하면 법원이 오늘날까지 포괄임금계약의 유효요건에 대하여 지속적으로 엄격하게 판단해 왔던 점, 무엇보다 그와 같은 엄격한 요건과 판단기준에 따라 결과적으로 근로자의 정당한 임금이 보전될 수 있도록 제도가 운영될 수 있다는 점, 나아가 해외사례를 보더라도 포괄임금계약의 전면적인

금지만이 문제 해결의 유일한 방안으로 보이지 않는다는 점을 고려할 때, 개정안에 대해서는 보다 더 면밀한 검토가 필요하다고 사료된다.

주제어: 포괄임금계약의 유효요건, 정액급제, 정액수당제, 당사자의 합의, 근로시간 산정의 어려움

목 차

|                           |
|---------------------------|
| I. 들어가며                   |
| II. 포괄임금계약의 의의와 유형        |
| III. 포괄임금계약의 유효요건         |
| IV. 포괄임금계약에 관한 개정안 및 해외사례 |
| V. 나오며                    |

I. 들어가며

이른바 ‘포괄임금제 또는 포괄임금계약’은 근로기준법 등 노동관계법령에서 정하고 있는 제도가 아니다. 법원이 대법원 1974. 5. 28. 선고 73다 1258 판결을 통해 사업장에서 관행적으로 이루어지던 임금지급 방식의 유효성을 인정한 후, 판례에 의해서 발전되어 온 제도이다. 노동시장에서 포괄임금제는 사용자가 근로자의 가산수당을 매번 계산하지 않아도 된다는 점, 통상적으로 근로자의 기본급이 높게 책정될 수 있다는 점 등 그 장점에도 불구하고 오남용의 우려로 인해 꾸준히 비판의 대상이 되어 왔다. 정부는 포괄임금계약의 오남용을 방지하기 위한 대책을 마련하여 시행하고 있다.<sup>1)</sup>

사용자와 근로자는 포괄임금계약을 통해서 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정과 다른 ‘임금지급 방식’을 정할 수 있으므로 그 유효성을 인정함에 있어서는 ‘엄격한 요건’을 요구한다. 왜냐하면 포괄임금계약은 법전에

1) 고용노동부는 2023년 1월부터 고용노동부 홈페이지에 ‘온라인 노사 부조리 신고센터’를 개설해 ‘사용자의 포괄임금 고정OT 오남용 신고’를 받고 있다.

명문화되어 있지 않으므로, 그 유효요건의 판단에 임의성이 개입될 여지가 상대적으로 크기 때문이다. 일반적으로 판례가 요구하는 엄격한 요건은, ① 근로시간 산정이 어려울 것 또는 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우에는 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼만한 특별한 사정이 있을 것, ② 당사자 간 합의가 있을 것, ③ 근로자에게 불이익하지 않고, 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 것 등이 있다. 다만 이러한 요건들은 일정한 사실관계에 따라 다르게 판단될 가능성을 내포한다. 따라서 위와 같은 요건들이 포괄임금계약에 관한 최초 판례부터 오늘날에 이르기까지 ‘통일적이고 일률적인 판단기준’으로 작동하고 있는지에 대해서는 의문을 갖게 된다.

법원의 판단 대상이 되었던 사건들에서도 대체로 포괄임금제 방식의 임금지급계약의 ‘유효성 요건’이 문제되었다. 판례는, 한편으로 포괄임금계약의 유효성을 인정하면서도, 다른 한편으로 그 오남용을 우려하여 꾸준히 유효요건을 보다 더 엄격하게 요구해 왔던 것으로 파악된다. 그리고 최근의 관련 판례를 살펴보면 포괄임금제의 유효성을 부정하는 경향이 강화되는 것으로 보인다. 이러한 사정을 반영하듯 지난 제21대 국회에 이어서 제22대 국회에서도 포괄임금계약을 규율하기 위한 근로기준법 일부개정법률안이 국회에 제출되어 있다.<sup>2)</sup>

이에 본고에서는 다음의 순서와 내용에 따라 포괄임금계약의 유효요건에 대한 대법원 판례의 변화추이를 검토하고자 한다. 우선 포괄임금계약의 의의와 유형에 관하여 정리해 본다(II). 다음으로 포괄임금계약의 유효요건<sup>3)</sup>에 대해서 살펴본다(III). 여기에서는 크게 ‘당사자의 합의’와 ‘근로시간 산정의 어려움’ 요건을 시간적 순서에 따라 검토하되, 각각의 점에 관한 구체적인 판례 검토에 집중하고자 한다. 이어서 포괄임금제에 대한 정책동향의 측면에서, 포괄임금제를 대하는 정부의 입장, 포괄임금계약에 관한 근로기준법 일부개정법률안, 나아가 포괄임금제로 이해할 수 있는 해외의 입법례에 관해서도 간략하게 소개해 보고자 한다(IV). 마지막으로 검토된 내

2) 2025. 4. 14. 현재 제22대 국회에는 포괄임금계약을 규율하기 위한 4개의 근로기준법 일부개정법률안이 제출되어 있는 것으로 파악된다. 이에 관하여 보다 자세한 것은 본고 IV.

3) 이하에서 다른 특별한 언급이 없는 한 ‘유효요건’은 포괄임금계약의 그것을 가리킨다.

용들을 요약하고, 포괄임금계약에 대한 법현실을 고려할 때 현재의 개정 방향이 그대로 유지되어야 하는지에 관하여 간략하게 언급하면서 본고를 마무리한다(V).

## II. 포괄임금계약의 의의와 유형

### 1. 서(序)

근로기준법 제17조 제1항은 사용자로 하여금 근로계약을 체결할 때 근로자에게 임금, 소정근로시간, 휴일(제55조), 연차 유급휴가(제60조), 그밖에 대통령령으로 정하는 근로조건을 ‘명시’하도록 규정한다. 동 조항에 따라 동법 시행령 제8조 제2호는 동법 제93조 제1호부터 제12호까지의 규정에서 정한 사항을 ‘명시’해야 할 근로조건으로 정하고 있다. 여기에는 ‘임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기’ 등이 포함된다. 무엇보다 근로기준법 제56조에 따라 사용자는 연장근로<sup>4)</sup>에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.

근로기준법 제17조와 제56조가 강행규정임은 주지하는 바와 같다. 따라서 원칙적으로 사용자는 근로계약을 체결할 때, 기본임금(통상임금)을 정하고, 이를 기초로 근로자가 연장근로, 야간근로, 휴일근로를 제공하는 경우 그에 상응하여 각각의 법정수당을 가산하여 지급해야 하며, 이러한 임금의 결정·계산·지급 방법 등은 사전에 명시되어야 한다. 그러나 근로기준법의 강행법규적 성질에도 불구하고, 실제 사업장에서는 위와 같은 규정 내용을 우회하여 근로시간, 근로형태와 업무의 성질 등을 참작해 ‘계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서’<sup>5)</sup> 기본임금을 미리 산정하지 아니한

4) 근로기준법 제53조(연장 근로의 제한), 제59조(근로시간 및 휴게시간의 특례) 및 제 69조(근로시간) 단서.

5) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카15939 판결; 대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카 32118 판결; 대법원 1995. 7. 28. 선고 94다54542 판결; 대법원 1997. 4. 25. 선고 95다4056 판결; 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결; 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결; 대법원 1999. 6. 11. 선고 98다26385 판결; 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다66995,67004 판결 등.

채 제 수당을 합한 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나, 기본수당을 미리 정하되 매월 일정액을 제 수당으로 지급하는 내용의 이른바 「포괄임금제 방식에 의한 임금지급계약(이하 ‘포괄임금계약’이라고 함)」이 체결되고 있다.<sup>6)</sup>

포괄임금제는 「대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결」을 통해 그 유효성을 처음으로 인정받은 이후 지속적으로 비판의 대상이 되어왔다. 특히 초과근로 상시화 등 장시간 근로를 고착화시켜 근로자의 일과 삶의 균형 및 재충전 기회를 불가능하게 한다거나, 실제 근로를 제공한 시간에 상응하여(기본임금+추가법정수당) 당연히 지급되어야 함에도 그에 미달하는 임금이 지급됨으로써 근로기준법이 강제하고 있는 임금과 근로시간에 관한 규정을 형해화한다는 비판을 받아왔다.<sup>7)</sup> 근래 우리 판례도 포괄임금제에 대한 비판적 시각을 반영하는 듯 포괄임금제의 유효성에 대하여 보다 엄격하고 제한적인 접근을 하는 것으로 파악된다.<sup>8)</sup>

그러나 포괄임금계약이 분명한 장점을 가지는 것도 사실이다.<sup>9)</sup> 근로시간, 근무형태와 업무의 성질 등에 비추어 실제 사업장에서 각각의 근로시간 산정이 어려운 경우나, 임금계산을 보다 간편하게 할 필요성이 있는 경우, 또는 업무의 성질상 연장근로나 휴일근로가 상시 예정될 수밖에 없는 경우에는 ‘효율성 내지 생산성 제고(提高)’라는 측면에서 포괄임금계약이 반드시 비판적으로만 볼 것은 아니라고 여겨진다. 포괄임금계약을 통한 효

6) 예를 들어 한국경제연구원의 보도자료(2019. 2. 11. 기준)에 따르면, 포괄임금제 실태조사 응답 기업 195개사(대상기업 600대 기업) 가운데 113개 기업(57.9%)이 포괄임금제를 도입하고 있다

(<https://www.mk.co.kr/economy/view.php?sc=50000001&year=2019&no=82078>, 2025. 4. 14. 최종확인).

7) 포괄임금제에 대하여, 사용자는 생산성과 효율성의 측면에서 긍정적인 제도로 받아들이는 반면, 근로자는 제공된 근로에 대하여 제대로 된 근로시간 산정이 이루어지지 않아 정당한 수당을 지급받지 못해 결국 ‘공짜노동’이 될 수밖에 없다고 인식하는 것으로 보인다. 예를 들어 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 노동법연구 26호(서울대학교 노동법연구회, 2008), 269면 등.

8) 임상민, “포괄임금제의 성립 및 유효요건”, 인권과 정의 502호(대한변호사협회, 2021), 97면.

9) 포괄임금제는 새로운 임금산정 방식으로서 널리 활용될 필요가 있다는 견해로서 정재현, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, (한국노동연구원, 2016), 50면 이하. 다만 이 견해도 포괄임금제의 운영과 적용상의 폐단에 대하여 지적하고 있다.

율성과 생산성 제고는 중국적으로 노사 모두에게 이익이 될 것이기 때문이다. 이러한 견지에서 우선 포괄임금계약의 의의와 유형에 관하여 살펴본다.

## 2. 포괄임금제의 의의

포괄임금제는 “사용자와 근로자가 기본임금을 미리 정하지 않은 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나, 기본임금을 미리 정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 않은 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수와 관계없이 지급하는 것”을 말한다.<sup>10)</sup> 포괄임금제에 관한 판례의 내용을 통해서 포괄임금제의 법적 의의는 다음과 같이 새겨도 좋을 것으로 판단된다.

① 포괄임금제는 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에 그 근거가 마련되어 있어야 한다. 즉 포괄임금제에 관한 계약이 필요한 것이다. 계약은 명시적 또는 묵시적으로 성립할 수 있으며, 그 여부는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 한다.<sup>11)</sup> 특히 단체협약이나 취업규칙 및 근로계약서에 ‘포괄임금’이라는 취지를 명시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 그 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 한다.<sup>12)</sup>

② 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우에는 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체

10) 대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899, 2018다206905(병합), 2018다206912(병합) 판결.

11) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결.

12) 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결.

결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다.<sup>13)</sup> 반면 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면, 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금 지급의 원칙이 적용되어야 한다. 만약 후자의 경우에 포괄임금계약을 체결한 때에는 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반했는지 여부가 문제된다. 포괄임금에 포함된 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달한다면 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금 지급계약 부분은 근로자에게 불이익하므로 무효가 될 것이다. 이로써 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의하여 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급해야 한다.<sup>14)</sup>

### 3. 포괄임금계약의 유형적 구별

판례는 포괄임금제 방식으로 정액수당제와 정액급제 방식의 유효성을 인정하고 있다. 정액급제는 기본임금과 법정수당을 구분하지 않는 형태를 말한다. 반면 정액수당제는 기본임금과 법정수당을 구분하되, 개별수당 간의 금액을 구분하지 않는 형태를 말한다. 두 유형을 비교하면 다음과 같다.

[표 1] 정액급제와 정액수당제의 구분

| 유형    | 내용                                            | 예시(단위: 만 원)               |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 정액급제  | 기본임금과 법정수당을 구분하지 않음                           | 임금 300<br>(연장, 야간, 휴일 포함) |
| 정액수당제 | 기본임금과 법정수당을 구분함.<br>다만 개별수당 간의 금액을<br>구분하지 않음 | 기본임금 230+수당 70=300        |

여기에서 기본임금과 법정수당을 구분하지 않는 ‘정액급제의 유효성’을

<sup>13)</sup> 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결; 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결.

<sup>14)</sup> 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결, 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결.

인정할 수 있을 것인지에 관하여 학설상 견해가 나뉜다. ‘긍정설’에 따르면, 비록 정액급제 방식이라 하더라도 이는 근로계약이나 단체협약에 의한 것이고, 근로자에게 실질적으로 불이익을 주지 않는 이상 근로기준법에 반하여 무효라고 할 것은 아니라고 한다. 반면, ‘부정설’에 따르면, 정액급제 방식은 기본임금과 제수당의 지급액이 전혀 구분되지 않아 근로기준법 제 17조(근로조건의 명시)에 정면으로 위배되므로 무효라고 한다.<sup>15)</sup>

정액급제에 관하여 판례는 “기본임금을 따로 정하지 아니하고 근로자의 승낙 아래 제수당을 미리 합산한 월급여액으로 지급하는 내용의 계약이라도 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때는 그 계약은 허용된다.”고 하여 정액급제 방식의 포괄임금 약정의 유효성을 인정하고 있다.<sup>16)</sup> 살피건대, 판례가 근로자의 승낙이 있어야 한다는 점, 근로자에게 불이익이 없어야 한다는 점, 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 수 있어야 한다는 점 등을 전제로 정액급제 방식의 유효성이 인정되기 때문에, 각 요건이 충족되는 경우에는 정액급제 방식의 포괄임금제 또한 유효하다고 할 수 있을 것이다.

다만, ① 근로자의 승낙은 그 자신의 ‘자유로운 의사결정’에 의하여야 하므로, 그러한 의사표시의 자율성을 판단함에 있어서는 근로자의 사용자에 대한 종속관계가 고려되지 않을 수 없을 것이다. 그리고 ② 근로자에게 불이익이 없는지 여부에 대한 판단에 있어서도 사용자와 근로자의 이익관계를 고려하여 엄격한 판단기준이 제시될 수 있어야 할 것이다. 무엇보다 ③ 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 수 있기 위해서는 제각각 상이한 구체적인 사실관계에서 각각의 사정들이 일률적인 판단기준에 따라 그 정당성이 판단될 수 있는 기준이 마련되어야 할 것이다.

위와 같은 점들을 고려하면, 포괄임금약정의 유형 가운데 포괄임금제의 부정적인 면을 보다 더 잘 소각(燒却)할 수 있는 형태는 「정액수당제→정액급제」의 순서라고 여겨진다. 반면 포괄임금계약을 인정하는 취지, 말하자면 계산의 편의성, 근로자의 근로의욕 고취,<sup>17)</sup> 그리고 근로시간 산정의

15) 학설대립에 관한 소개로서 임상민, 위의 논문(주 8), 100면.

16) 대법원 1982. 3. 9. 선고 80다2384 판결대법원 1983. 9. 13. 선고 82다카49 판결대법원 1984. 1. 24. 선고 83도2068 판결대법원 1987. 8. 18. 선고 87다카474 판결대법원 1987. 8. 18. 선고 87다카474 판결대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카6934 판결대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결 등.



어려움을 합리적으로 해결한다는 점이 적절하게 실현될 수 있다면, 포괄임금계약을 정액급제의 형식으로 정하더라도 무리가 없을 것이다.<sup>18)</sup>

무엇보다 위와 같은 정액급제와 정액수당제의 「부정적 측면」을 고려할 때, 실질적으로나 형식적으로도 그러한 부정적 측면이 없는 ‘고정OT’ 방식의 임금체계가 포괄임금제에 해당하는지에 관하여 의구심을 갖게 된다. 이에 대해서는 후술하기로 한다.

### III. 포괄임금계약의 유효요건

#### 1. 당사자의 합의(Vereinbarung)

##### 1) 합의의 의의

포괄임금제 방식의 임금 지급이 유효하기 위해서는 「무엇보다 최우선적으로」 단체협약, 취업규칙, 근로계약 등에서 그에 대한 임금 지급계약, 즉 포괄임금제에 대한 청약과 승낙의 합치(=합의)가 요구된다. 일반적으로 법률행위로서 합의는 ‘명시적 합의’뿐만 아니라 ‘묵시적 합의’도 인정될 수 있다. 즉 “일반적으로 계약이 성립하기 위하여는 청약과 승낙이라는 서로 대립하는 의사표시가 합치될 것을 요건으로 하는 것이지만, 그러한 의사표시는 명시적인 경우뿐만 아니라 묵시적으로도 이루어질 수 있는 것이다. 한편, 어떠한 경우에 묵시적 의사표시를 통해 계약이 성립되었다고 볼 수

17) 대법원 1995. 7. 28. 선고 94다54542 판결; 대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결; 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결; 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결; 대법원 2005. 6. 9. 선고 2005도1089 판결. 계산의 편의성과 근로자의 근로의욕 고취를 언급하는 비교적 최근의 판례로서 대법원 2014. 12. 24. 선고 2014도12265 판결.

18) 그럼에도, 앞서 지적했듯이, 포괄임금제가 저임금, 장시간 근로에 악용될 수 있다는 비판이 계속해서 있어 왔고, 근래의 판례는 그러한 비판을 수용하는 듯 특히 계산의 편의성이나 근로자의 근로의욕 고취 등을 언급함이 없이 포괄임금계약의 유효성에 대하여 엄격하게 제한하거나 해석하는 것으로 보인다. 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결 등. 2009년 이후 최근의 판례가 포괄임금제의 성립 또는 유효성에 관하여 과거보다 다소 엄격하게 판단하고 있다는 임종률, 『노동법』 (제20판), 박영사, 2022, 479면 이하.

있는지는 당사자들이 취한 일련의 행위 또는 용태, 묵시적 합의에 이르게 된 동기 및 경위, 그 합의의 내용 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙에 따라 판단하여야 한다.”<sup>19)</sup> 다만 포괄임금계약이 근로기준법이 명시적으로 규정하는 임금지급 방식과 다른 방식이라는 점에서, 포괄임금계약의 사례에서도 묵시적 합의를 인정할 수 있을 것인지 문제될 수 있다.

종래 판례는 포괄임금약정에 대한 묵시적 합의를 비교적 넓게 인정했던 것으로 보인다.<sup>20)</sup> 예를 들어 아파트 경비원 또는 보일러공으로 1일 24시간씩 격일 근무하기로 하고 채용되어 소정 임금을 매월 지급받아 온 사건에서 판례는 “위 근로계약은 아파트 경비관리라는 근로형태의 특수성 때문에 근로기준법상의 기준근로시간을 초과한 연장근로와 야간, 휴일근무가 당연히 예상되는 근로계약이었으므로 공소외인들이 지급받은 판시 임금에는 근로기준법상 기준근로시간인 1일 8시간, 주 48시간 근무에 대한 임금 외의 연장근로와 휴일, 야간근로에 대한 수당도 포함된 것으로 보아야 할 것이”라고 판단하였다.<sup>21)</sup>

반면 최근의 판례는 포괄임금약정에 대한 묵시적 합의의 유효성 판단기준을 제시하면서 그 인정에 보다 엄격한 태도를 취하는 것으로 보인다. 즉 “포괄임금제에 관한 약정이 성립하였는지 여부는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 하며, 비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당을 세부항목으로 명백히 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우는 포괄임금제에 해당하지 아니한다고 할 것이고, 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의가 있다거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선

19) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2011다30765 판결.

20) 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 성균관법학 23권 3호(성균관대학교 법학연구원, 2011); 임상민, 위의 논문(주 8).

21) 대법원 1983. 10. 25. 선고 83도1050 판결. 또한 대법원 1984. 1. 24. 선고 83도 2068 판결; 대법원 1991. 4. 9. 선고 90다16245 판결.

불리 단정할 수는 없다.”고 판시하였다.<sup>22)</sup> 동 판결 이후 판례는 같은 태도를 유지하는 것으로 파악된다.<sup>23)</sup>

특히 판례는 “단체협약이나 취업규칙 및 근로계약서에 포괄임금이라는 취지를 명시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 한다.”고 판시하였다.<sup>24)</sup>

## 2) 합의의 대상

포괄임금계약에는 연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당 또는 연월차휴가수당 등이 포함될 수 있다. 여기에서 휴일근로수당이나 연월차휴가수당에 대한 포괄임금약정은 그 자체로 모순이라는 지적이 있다. 휴일근로수당이나 연월차휴가수당은 휴가를 사용하지 않을 경우에 비로소 발생한다는 것이 그 이유이다.<sup>25)</sup> 일견 타당한 지적으로 보인다. 그러나, ① 휴일근로수당과 연월차휴가수당은 그 성질상 구분될 수 있고, 휴일근로수당은 연장근로 및 야간근로와 동일한 평면에서 논의할 필요가 있다. 왜냐하면 연

22) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결; 대법원 2017. 7. 11. 선고 2015도13909 판결; 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579(본소), 2015다233586(반소) 판결; 대법원 2022. 2. 11. 선고 2017다238004 판결.

23) 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결; 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결; 대법원 2017. 7. 11. 선고 2015도13909 판결; 대법원 2022. 2. 10. 선고 2018다298904 판결; 대법원 2021. 11. 11. 선고 2020다224739 판결; 대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899 판결. 한편, 포괄임금제가 인정되기 위해서는 -비록 구두일지라도- 명시적 합의가 요구된다는 견해로서 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 노동법학 29호(한국노동법학회, 2009), 353면.

24) 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결.

25) 강성태, 위의 논문(주 7), 273면; 이광선, “포괄임금 약정의 효력과 문제점”, 저스티스 141호(한국법학원, 2014), 353면 이하; 조임영, “포괄임금제에 의한 임금 지급계약의 성립요건”, 노동법률 95호(중앙경제사, 1999), 47면.

장근로, 야간근로, 휴일근로는 ‘근로형태나 업무의 성질’에 비추어 당연히 예상이 가능할 수 있다는 점에서<sup>26)</sup>, 통상적으로 개인의 사유에 의하여 발생 여부가 좌우되는 연월차휴가수당과는 구별될 수 있기 때문이다.<sup>27)</sup> ② 휴일근로수당과 연월차휴가수당을 구분하지 않더라도, 두 수당뿐만 아니라 연장근로수당과 야간근로수당 역시 ‘일정한 요건’하에서 발생할 수 있다는 점은 마찬가지다. 따라서 포괄임금계약에는 휴일근로수당이나 연월차휴가수당이 포함될 수 있다고 해야 할 것이다. 판례도 같은 입장이다.

판례는 “연차수당이 근로기준법에서 정한 기간을 근로하였을 때 비로소 발생하는 것이라 할지라도 당사자 사이에 미리 그러한 소정기간의 근로를 전제로 하여 연차수당을 일당 임금이나 매월 일정액에 포함하여 지급하는 것이 불가능한 것이 아니며, 포괄임금제란 각종 수당의 「지급방법」에 관한 것으로서 근로자의 연차휴가권의 행사 여부와는 관계가 없으므로 포괄임금제가 근로자의 연차휴가권을 박탈하는 것이라고 할 수 없다.”고 판시하였다.<sup>28)</sup> 그리고 월급에 포함되어 지급된 연차수당액이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 정당한 연차수당액에 미달하는 경우 그 미달된 부분에 한하여 무효가 된다.<sup>29)</sup> 예를 들어 근로자가 15일의 연차휴가를 가지는 사안에서, 포괄임금에 포함되어 연차수당으로 지급된 금액이 10일의 연차분에 해당함에도, 근로자가 실제로 15일의 연차를 사용하지 못하였다면, 그 미달 부분인 5일분에 대하여만 포괄임금 약정의 효력이 무효가 된다. 사용자는 근로자에게 그 5일분의 연차수당을 지급할 의무를 부담한다. 반면, 근로자가 7일의 연차휴가를 사용하더라도 2일분의 연차수당액을 반환

26) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결; 대법원 2017. 7. 11. 선고 2015도 13909 판결; 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579(본소), 2015다233586(반소) 판결; 대법원 2022. 2. 11. 선고 2017다238004 판결.

27) 근로기준법 제60조(연차 유급휴가)

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

28) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결; 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019다 29778 판결.

29) 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019다29778 판결; 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다 6052 판결.

할 필요가 없다.<sup>30)</sup> 한편 퇴직금은 포괄임금에 포함될 수 없다.<sup>31)</sup> 그리고 포괄임금계약이 체결되었으나 ‘최저임금’에 미달하는 임금이 지급되었다면 해당 약정부분은 무효가 된다.<sup>32)</sup>

### 3) 검토

포괄임금제에 대한 당사자 간의 명시적·묵시적 합의가 ‘유효’하기 위해서는 다음의 요건이 충족되어야 할 것이다. ① 포괄임금계약이 「체결」되었는지 여부는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단해야 한다. ② 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 명백히 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우는 포괄임금제에 해당하지 않는다. 즉 포괄임금제의 묵시적 약정을 인정할 수 없다. ③ 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정되고, 사용자와 근로자 사이에 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도

30) 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 인권과 정의 347호(대한변호사협회, 2005), 72면 이하. 같은 취지에서 노사 간에 실제의 연장근로시간과 관계없이 일정 시간을 연장근로시간으로 간주하기로 합의하였다면 사용자로서는 근로자의 실제 연장근로시간이 위 합의한 시간에 미달함을 이유로 근로시간을 다투는 것이 허용되지 않는다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2015다44069 판결; 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결 등).

31) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결; 대법원 1973. 10. 10. 선고 73다278 판결; 대법원 1991. 6. 28. 선고 90다14560 판결; 대법원 1996. 5. 14. 선고 95다19256 판결: “퇴직금이란 퇴직이라는 근로관계의 종료를 요건으로 하여 비로소 발생하는 것으로 근로계약이 존속하는 한 퇴직금 지급의무는 발생할 여지가 없는 것이므로, 매일 지급받는 일당임금 속에 퇴직금이란 명목으로 일정한 금원을 지급하였다고 하여도 그것은 구 근로기준법 제28조에서 정하는 퇴직금 지급으로서의 효력은 없다.”

32) 대법원 2016. 9. 8. 선고 2014도8873 판결: “이 사건 근로자들에게 포괄임금제를 적용함으로써 최저임금법에서 정한 최저임금에도 못 미치는 임금을 지급하여 이들에게 불이익이 있으므로, 이 사건 근로자들에 대한 포괄임금제 약정 중 최저임금에 미달하는 금원에 해당하는 부분은 무효”이다.

지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되어야 한다.

바꾸어 말하면, 다음의 경우에는 포괄임금제에 해당하지 않게 된다. 즉, ① 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도, 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 명백히 나누어 지급하도록 정하고 있는 경우, ② 사용자와 근로자 사이에 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 ‘초과 연장근로’에 대하여 추가로 수당을 지급하도록 정하고 있는 경우 등이다.<sup>33)</sup>

## 2. 유효요건에 관한 대법원 판례의 변화 양상

### 1) 서(序)

주지하듯이 -포괄임금제 방식의 임금 지급에 대한 당사자의 합의와 함께 - 오늘날 포괄임금계약의 유효성 판단에 있어 판례의 가장 중핵적인 판단 기준은 「근로시간 산정의 어려움」 여부이다. 그러나 판례가 처음부터 근로시간 산정의 어려움을 포괄임금계약의 유효요건으로 채택한 것은 아니다. 말하자면 1974년 처음 포괄임금계약의 유효성을 인정한 이후 그 판단 기준은 시간의 흐름에 따라 조금씩 변화를 겪게 되었다. 무엇보다 포괄임금제에 대한 지속적인 비판이 있어 왔고, 판례는 그러한 비판을 수용하는 듯 서서히 유효요건을 보다 엄격하게 요구하는 것으로 파악된다. 이하에서는 포괄임금계약의 유효성에 관한 ① 최초 판례, ② 1980년대 판례, ③ 1990년대부터 2000년 후반까지 판례의 변화 양상을 정리한다. 그리고 목차를 달리하여 2009년 판례<sup>34)</sup>를 기점으로 보다 엄격하게 변화했다고 평가받는 판례의 판단기준을 이른바 ‘근로시간 산정의 어려움’ 요건을 중심으로 보다 자세히 살펴본다(이어지는 목차 3).

### 2) 초기 판례의 태도

<sup>33)</sup> 위와 같은 점들을 고려할 때, 정액급제와 정액수당제에 비추어 ‘고정OT’가 포괄임금제에 해당하는지 여부가 문제될 수 있을 것이다.

<sup>34)</sup> 대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결.

판례는 「대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결」을 통해 처음으로 포괄임금계약의 유효성을 인정한 것으로 파악된다.<sup>35)</sup> 위 대법원 판례는 원심의 판단을 그대로 따르고 있으므로, ‘포괄임금약정의 유효성’과 관련되는 범주에서 원심의 내용을 살펴본다.

(1) 서울고등법원 1973. 6. 29 선고 72나1004 판결

가) 인정 사실

① 원고들은 별표 (가)항 표시 일자에 국내에서 피고와 1차 계약을 각 체결하였다.

② ‘1차 계약에 따르면, ㉠ 근로시간은 1일에 10시간, 1주일에 60시간 및 1개월에 260시간을 원칙으로 하되 1주일에 10시간의 휴일근로를 연장할 수 있도록 하였다. ㉡ 임금은 월의 대소를 막론하고 30일을 기준으로 하여 월급으로 매달 1일부터 말일까지 산출한 임금을 다음 달 10일에 일괄하여 지급하되, 원고들의 월임금 총액은 별표 (라)항 기재와 같이 월 340불이었다.

③ 1차 계약이 종료됨과 동시에 다시 ‘2차 계약’을 맺고 근로시간, 임금 지급방법 등은 1차 계약내용과 동일하지만 원고들의 월임금 총액은 별표 (라)항 기재와 같이 월 390불로 약정하였다. 그리고 2차 계약에 따르면, ㉠ 고용기간 동안에 원고들은 피고와 합의한 바에 따라 주휴일 및 월차, 연차휴가를 받지 아니하고 계속하여 05:30부터 다음 날 같은 시각까지 휴게시간 4시간을 공제한 20시간을 근무하고, 다음 날은 완전히 휴식하는 내용의 격일제 근무를 하면서 소정의 임금을 모두 지급받았다(연장근무시간 2시간에 대한 수당도 받았다). ㉡ 취업기간 동안 근로하는 날의 20시간 중에는 6시간 30분 동안의 야간근무가 포함되어 있었다. ㉢ 원고들은 피고로부터 별표 (타)항 기재와 같은 내용의 제수당(연장근무수당, 야간근무수당, 주휴일근무수당 및 기타 수당)을 합산하여 별표 (라)항 기재와 같은 월임금 총액을 받았다.

<sup>35)</sup> 하갑래, 위의 논문(주 23), 326면; 임상민, 위의 논문(주 8), 99면 각주 10); 김홍석, “포괄임금제에 관한 법적 성격과 쟁점”, 법학연구 34권 2호(충남대 법학연구소, 2023), 82면.

## 나) 연월차유급휴가수당 청구에 대한 판단

피고는 원고들에게 각 원고가 위 월차, 연차유급휴가일에 근로한데 대한 수당을 지급하여야 할 것인바, 유급휴일에 근로한 근로자에게 지급되는 임금에는 유급으로서 당연히 지급되는 임금과 유급휴가의 근로에 대한 소정의 통상임금을 포함한다고 되어 있는바, 유급으로서 당연히 지급되는 임금은 이미 기본임금에 포함되어 있고, 피고가 원고들에게 지급하여야 할 월차 유급휴가 근로수당을 매월 단위로 산정하여 보면 별표 (자)항 기재의 각 금액이 되고, 연차유급휴가 근로수당을 매월 단위로 산정하여 보면 별표 (차)항 기재의 각 금액이 된다.

## 다) 그 이외 연장근로수당, 야간근로수당 및 주휴일 근로수당

원고들이 피고에 대하여 청구할 수 있는 근로기준법상 월단위 제수당의 합계액은 별표 (카)항 기재의 각 금액이 되는데, 앞서 인정된 바에 의하면 피고는 원고들에게 별표 (마)항 기재의 기본임금 및 피고가 원고들에게 지급하여야 할 근로기준법상의 제수당으로서 실제로 지급한 합계로서 별표 (타)항 기재의 금액의 ‘합산액인 별표 (라)항 기재의 각 금액’을 매월 지급한 것임을 알 수 있으므로, 피고가 원고들에게 제수당의 명목으로 지급한 별표 (타)항 기재의 각 금액이 피고가 원고들에게 지급하여야 할 법정 제수당의 합산액인 별표 (카)항 기재의 각 금액을 별표 (하)항 기재의 각 금액만큼 초과하고 있음이 산수상 명백하다. 따라서 원고들이 이전에서 청구하고 있는 월차, 연차유급휴가근로수당은 이미 모두 지급된 것이라고 아니 할 수 없다.

## (2) 대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결

원고들은 패소 이후, ‘야간근로시간, 연장근로시간, 주휴근무일수, 월차 및 연차유급휴가, 근로일수 등은 어떤 기간 동안 실제로 근무를 마친 후에 비로소 따질 수 있는 것이지, 근로계약 체결 시에 미리 예정할 수 없는 것’이라는 이유에서 상고하였다.

위 상고이유에 대하여 대법원은 “「고용기간 동안에 원고들은 피고와 합의한 바에 따라 주휴일 및 월차, 연차 유급휴가를 받지 아니하고 계속하



여 05:30부터 다음날 같은 시각까지 휴게시간 4시간을 공제한 20시간을 근무하고 그 다음 날은 완전히 휴식하는 내용의 격일제 근무」를 하기도 하였다는 것이니, 이와 같은 방식의 근무를 한 번의 결근도 없이 계속한다는 것을 전제로 하면 근로기간 중 연장근로, 야간근로, 휴일근로 및 월, 연차 유급휴가근로 시간을 미리 예상하여 그 수당을 산출할 수 있는 것이고, 그와 같이 산출한 제수당을 근로계약서에 임금내역으로 표시할 수 있다.”고 판시하였다.

### (3) 검토

판례는 ‘서울고등법원 1973. 6. 29 선고 72나1004 판결’과 ‘대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결’에서 연장·야간·휴일근로 및 연월차유급휴가근로 시간을 미리 예상하여 그 수당을 산출할 수 있고, 그와 같이 산출한 제수당을 ‘포괄하여’ 미리 근로계약서에 임금내역으로 표시할 수 있다고 판시하였다. 이러한 판례의 태도는, 각 개별수당을 구분하여 임금계약서에 표시하고 그에 따라 실제 제공한 초과 근로시간에 상응하는 각 수당을 지급하지 않더라도, 「결과적으로」 실제 지급받은 제수당이 법정수당을 충족하면, 이로써 그와 같은 포괄적인 임금계약도 인정될 수 있다는 취지로 이해된다. 다만 위 판례에서는 이른바 ‘포괄임금계약의 유효요건’에 대하여 구체적으로 실시하지는 않았다. 그러나 위 판결 이후 판례는 조금씩 포괄임금계약의 유효요건을 구체화하는 것으로 파악된다.

## 3) 1980년대 판례

### (1) 변화 추이

대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결 이후, 판례는 「대법원 1982. 3. 9. 선고 80다2384 판결」에서 ‘기본임금을 따로 정하지 않고 제수당을 미리 합산한 일정금액을 월급여액으로 정한 근로계약의 효력’에 관하여, “노동계약체결시에 기본임금을 미리 결정하지 아니하고, 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등에 대한 제수당을 미리 합산한 일정금액을 근로자의 승락하에 월급여액으로 지급하는 내용의 계약을 체결하였다고 하더라도 근로자에게 불이익이 없고, 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를

무효라고 할 수 없다.”고 판단하였다.

이후 ‘대법원 1982. 12. 28. 선고 80다3120 판결’에서는 “근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 등을 참작하여 근로자의 승락하에 매월 일정액을 위 제수당으로 지급하는 내용의 계약을 체결하였다고 하더라도 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를 무효라고 할 수 없다.”고 판시하였다.

‘대법원 1983. 10. 25. 선고 83도1050 판결’에서는 “아파트 경비원 또는 보일러공으로 1일 24시간씩 격일 근무하기로 하고 채용되어 소정 임금을 매월 지급받아 온 경우에 있어서 위 근로계약은 아파트 경비관리라는 근로형태의 특수성 때문에 근로기준법상의 기준근로시간을 초과한 연장근로와 야간, 휴일근무가 당연히 예상되는 근로계약이었으므로 위 지급임금에는 근로기준법상 기준근로시간인 1일 8시간, 주 48시간 근무에 대한 임금외의 연장근로와 휴일, 야간근로에 대한 수당도 포함된 것으로 보아야 한다.”고 판시하였다.

‘대법원 1987. 8. 18. 선고 87다카474 판결’에서는, “기본임금을 별도로 결정하지 아니하고 제수당을 미리 합산한 일정금액을 근로자의 승낙하에 월급여액으로 지급하는 내용의 계약을 하였다 하더라도 단체협약이나 취업규칙에 비추어 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 그 계약은 허용된다.”고 판시하였다.

## (2) 검토

1980년대 판례가 제시하는 ‘포괄임금계약의 유효요건’은 다음과 같이 정리할 수 있을 것이다.

- ① 근로자의 승낙(=당사자의 합의)
- ② 단체협약이나 취업규칙 등에 비추어 + 근로자에게 불이익이 없을 것
- ③ 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 것
- ④ 근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 등을 참작(=근로형태의 특수성)
- ⑤ 연장근로와 야간, 휴일근무가 당연히 예상되는 근로

요컨대 1980년대 판례는 최초의 판례 이후 유효요건을 구체화하고 있으나, 오늘날과 같이 엄격하게 요구하지는 않는 것으로 보인다. 즉 포괄임금의 유효성에 대하여 상대적으로 완화된 입장을 가졌다고 평가될 수 있을

것이다.

#### 4) 1990년대 이후 판례

1990년대에 들어서 판례는 포괄임금계약의 유효요건으로서 이른바 ‘계산의 편의’와 ‘직원의 근로의욕 고취’를 제시한다. 판례는 「대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카15939 판결」에서 “위 근무수당은 실제 근무실적에 따라 지급되는 시간외, 야간 및 휴일근무수당을 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취시키는 취지에서 일정한 실제 근무시간을 기준으로 하여 매월 고정액 또는 감액조정액으로 지급키로 한 것으로서 근로자에게 불이익한 것이 아닌 한 유효하다고 할 것이고, 따라서 근로자가 이러한 근무수당을 이미 지급 받았다면 이와 별도로 휴일근무수당을 청구할 수는 없다.”고 판시하였다.

이후 ‘대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결’에서는 유효요건을 보다 구체화하여 “실제 근무실적에 따라 지급되어야 할 시간외, 야간 및 휴일수당 등을 근로시간 및 근로형태와 업무의 성질 등을 참작하고 계산의 편의와 직원의 근무의욕을 고취하는 뜻에서 매월 일정액을 제수당으로 지급하는 내용의 계약을 체결하였다 하더라도 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를 무효라 할 수 없다.”고 판시하였다. 그리고 위와 같은 판례의 태도는 「대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결」 전까지 계속 유지된 것으로 파악된다.<sup>36)</sup>

살피건대, 당시까지 판례가 제시한 포괄임금약정의 유효요건은 여전히 추상적으로 여겨진다. 따라서 포괄임금약정의 유효성 판단에는 임의적 해석의 가능성이 폭넓게 남아 있었고, 이는 곧 포괄임금약정에 대한 판례의 관대한 입장으로 이해되기도 한다. 그러나 ‘대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결’을 기점으로 판례가 포괄임금 약정에 대하여 엄격한 판단을 하는 것으로 파악된다. 무엇보다 「근로시간 산정의 어려움」 요건이

<sup>36)</sup> 대법원 1995. 7. 28. 선고 94다54542 판결; 대법원 1997. 4. 25. 선고 95다4056 판결; 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결; 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결; 대법원 1999. 6. 11. 선고 98다26385 판결; 대법원 2005. 6. 9. 선고 2005도1089 판결; 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다66995,67004 판결. 또한 대법원 2014. 12. 24. 선고 2014도12265 판결.

중핵적인 판단기준으로 제시되었다.

### 3. 「근로시간 산정의 어려움」 요건

#### 1) 최근 판례의 동향

‘대법원 2009. 12. 10. 선고 2008다57852 판결’을 기점으로 판례는 포괄임금계약의 유효요건에 대하여 엄격하게 판단하는 것으로 평가되고 있다.<sup>37)</sup> 특히 「대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결(이하 「대상판결」이라고 함)」에서 판례는 포괄임금 약정이 유효하기 위한 요건으로서 무엇보다 「근로시간 산정의 어려움」<sup>38)</sup>을 제시하였고, 오늘날 유효성 판단에 있어서는 ‘근로시간 산정의 어려움’이 -유일하지는 않지만- 가장 중대한 판단기준으로 이해된다.

‘대상판결’에서 판례는 먼저 “사용자는 근로계약을 체결함에 있어서 기본임금을 결정하고 이를 기초로 하여 근로자가 실제로 근무한 근로시간에 따라 시간외근로·야간근로·휴일근로 등이 있으면 그에 상응하는 시간외근로수당·야간근로수당·휴일근로수당 등의 법정수당을 산정하여 지급함이 원칙”이라고 전제한 후, “이러한 원칙적인 임금지급방법은 근로시간 수의 산정을 전제로 한 것인데, 예외적으로 감시단속적 근로 등과 같이 근로시간, 근로형태와 업무의 성질을 고려할 때 근로시간의 산정이 어려운 것으로 인정되는 경우가 있을 수 있고, 이러한 경우에는 사용자와 근로자 사이에 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 아니한 채 일정액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금 지급계약을 체결하더라도 그것이 달리 근로자에게 불이익이 없고 여러

37) 심재진, “포괄임금제의 쟁점과 전망”, 노동법학 64호(한국노동법학회, 2017); 임상민, 위의 논문(주 8); 김기선, “26. 포괄임금제의 성립요건과 효력”, (노동판례백선, 2021); 김홍석, 위의 논문(주 35) 등.

38) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2011도12114 판결; 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결; 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019다29778 판결; 대법원 2024. 2. 8. 선고 2018다206899, 206905, 206912 판결.

사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다.”고 판시하였다.

그러나 “근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 달리 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 (中略) 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 할 것이므로, 이러한 경우에도 근로시간 수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 포괄임금계약을 체결하는 것은 그것이 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다.”고 전제한 후, “근로시간의 산정이 어려운 등의 사정이 없음에도 포괄임금제 방식으로 약정된 경우 그 포괄임금에 포함된 정액의 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 때에는 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의해 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다.”고 판시하였다.

그리고 대법관결은 상고이유에서 인용한 ‘대법원 1997. 4. 25. 선고 95다4056 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결’과 관련하여, 동 “판결들의 판시 각 사안은 모두 근로형태나 업무의 성질 등에 비추어 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’에 해당하는바, 위 대법원 판결들이 판시하는 법리는 위와 같이 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당하는 사안에서 이와 달리 근로시간의 산정이 가능한 것을 전제로 하여 근로기준법상의 법정수당과의 차액을 청구하는 것은 받아들일 수 없다’는 취지라 할 것이고, 나아가 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우 등이 아니라 하더라도 실근로시간과 무관하게 법정수당을 정액으로 정하는 포괄임금계약이 유효하게 성립될 수 있다’는 취지까지 포함하는 것은 아니”라고 판시하였다.

그리고 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결은 “사용자와 근로자 사이에 기준 근로시간을 초과한 근로 등에 대하여 매월 일정액을 제수당으로 지급한다는 내용의 포괄임금제에 의한 임금지급계약이 체결된 경우, 근로자가 포괄임금으로 지급받은 연장근로수당 또는 이에 갈음한 시간외수당, 야간수당, 휴일수당 등에는 근로기준법의 규정에 의한 시간외근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당이 모두 포함되어 있다고 볼 것이어서, 근로자의 구체적인 시간외 근로시간 등을 인정하고 포괄임금으로 지급된 제수당과 시간외 근로 등에 대한 근로기준법의 규정에 의한 수당과의 차

액의 지급을 명한 원심에는 포괄임금제에 관한 법리오해의 위법이 있다.”고 판시하였다.

살피건대, 위 “대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결”과 “대상판결(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결)”의 판시 내용에 비추어 보면, 결국 근로시간 산정이 어려운 경우이든 어렵지 않은 경우이든, ‘임금지급 계약의 내용’에 비추어 근로자가 「고정시간외수당(이른바 ‘고정OT’)」 외에 그 기준시간을 초과하는 연장근로에 대하여 ‘초과 연장근로수당’을 청구할 수 없다고 인정되는 경우에 그 임금지급 계약은 ‘포괄임금계약’에 해당한다는 것을 알 수 있다. 위 대상판결에 따라 ‘포괄임금계약의 유효요건’은 다음과 같이 정리할 수 있을 것이다.

- ① 원칙적으로 사용자는 근로계약을 체결함에 있어 ‘기본임금’을 결정하고, 이를 기초로 하여 근로자가 실제로 근무한 초과근로시간에 따라 그에 상응하는 시간외근로수당·야간근로수당·휴일근로수당 등의 법정수당을 산정하여 지급해야 한다.
- ② 근로시간 수의 산정이 어려운 경우에는, ㉠ 기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 법정수당까지 포함된 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정할 수 있다(이른바 ‘정액급제’ 방식). ㉢ 기본임금을 미리 산정하면서도 법정 제 수당을 구분하지 아니한 채 일당액을 법정 제 수당으로 정하여 이를 근로시간 수에 상관없이 지급하기로 약정할 수 있다(이른바 ‘정액수당제’ 방식). ㉣ ‘정액급제’ 방식이든 ‘정액수당제’ 방식이든, 근로자에게 불이익이 없어야 하고(and), 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 수 있어야 한다.
- ③ 근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우에는, ㉠ 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 한다. ㉢ 포괄임금에 포함된 정액의 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 때에는 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효이다. ㉣ 사용자는 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다.
- ④ 사용자와 근로자가 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정과 다른 방식의 임금지급계약을 체결한 경우, 당해 계약의 내용에 비추어 근로자가 고정시간외수당(고정OT) 외에 그 기준시간을 초과하는 연장근로에 대하여 ‘초과 연장근로수당’을 청구할 수 없다고 인정되는 때에 그 임금지급 계약은 ‘포괄임금계약’에 해당할 수 있다.

요컨대 포괄임금계약의 유효성과 관련하여 대상판결이 갖는 의의는 다음과 같다고 여겨진다.

첫째, 사용자와 근로자는 근로기준법이 정하는 원칙적인 방식과 다른 방

식, 즉 ‘포괄임금제 방식’으로 임금 지급계약을 체결할 수 있다.

둘째, 포괄임금계약의 유효성 요건은 ‘근로시간 수의 산정이 어려운 경우’와 ‘근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우’로 나누어 검토되어야 한다.

셋째, 전자에서는 ① 근로시간 수의 산정이 어려울 것, ② 근로자에게 불이익이 없을 것, ③ 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 것 등 3가지 요건이 충족되어야 한다. 반면 후자에서는 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 존재해야 한다.

넷째, 근로시간 산정이 어려운 경우이든 어렵지 않은 경우이든, ‘임금지급 계약의 내용’에 비추어 근로자가 고정시간외수당(고정OT) 외에 그 기준시간을 초과하는 연장근로에 대하여 ‘초과 연장근로수당’을 청구할 수 없다고 인정되는 때에 그 임금지급 계약은 ‘포괄임금계약’에 해당할 수 있다.

이하에서는 ‘근로시간 수의 산정이 어려운 경우’와 ‘근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우’를 나누어 각각의 요건들에 관하여 보다 구체적으로 살펴본다.

## 2) 근로시간 수의 산정이 어려운 경우

### (1) 원칙: 각 개별사실에 따른 구체적 판단

대상판결은 근로시간 수의 산정이 어려운 경우를 판단하기 위한 통일적인 기준을 제시하고 있지 않다. 결국 각각의 개별사실에 따라 구체적인 사실관계를 종합적으로 고려하여 판단할 수밖에 없을 것이다.

① 우선 대상판결에서는 감시·단속적 근로를 근로시간 수의 산정이 어려운 경우로 명시하고 있다. 근로기준법은 감시·단속적 근로에 종사하는 사람에 대하여 근로시간 등의 적용 예외를 인정한다(동법 제63조 제3호). 여기에서 감시적 근로는 감시업무를 주 업무로 하며 상태적(狀態的)으로 정신적·육체적 피로가 적은 업무를 말한다(근로기준법 시행규칙 제10조 제2항). 단속적 근로는 근로가 간헐적·단속적으로 이루어져 휴게시간이나 대기시간이 많은 업무를 말한다(동조 제3항). 감시·단속적 근로에 종사하는

자는 통상적으로 근로 중 휴식을 충분히 취할 수 있고<sup>39)</sup> 노동의 강도나 신체적·정신적 부담이 상대적으로 높지 않기 때문에<sup>40)</sup>, 고용노동부 장관의 승인을 받아 근로시간에 관한 규정이 적용되지 않을 수 있다.<sup>41)</sup>

그러나 감시·단속적 근로라고 하더라도, 예를 들어 감시적 업무이기는 하나 잠시도 감시를 소홀히 할 수 없는 고도의 정신적 긴장이 요구되는 경우 또는 타 업무를 반복하여 수행하거나 겸직하는 경우는 근로시간 등의 적용 제외 대상에서 배제된다.<sup>42)</sup> 판례는 대학교 수위로 근무한 원고들이 연장근로수당의 지급을 청구한 사건에서, “그 업무의 성질이나 근로형태로 보아서는 시간외, 야간, 휴일근로가 예상된다고 할 수 있으나, 피고 법인의 단체협약, 교직원복무규정 및 급여규정상으로는 직원들에 대한 급여의 지급이 이른바 포괄임금제에 의하도록 규정되어 있지 아니함을 알 수 있고, 더욱이 근로시간이 당초 근로계약을 맺을 때보다 더 증가하여 근로조건이 중간에 불리하게 변경되었다면 원고들이 피고 법인과 사이에 장차 증가될 근로시간에 대한 임금까지 포괄하여 일정액만을 받기로 하는 근로계약을 체결하였다고 볼 수는 없으며, 또한 원고들이 중간에 불리하게 변경된 근로조건을 무조건 동의하였다고 볼 수도 없다.”는 이유에서 대학교 수위의 임금 지급 형태가 그 구체적 사정에 비추어 포괄임금제에 해당되지 않는다고 판단하였다.<sup>43)</sup>

② 사업장 외에서 근로를 제공하는 경우 근로시간 수의 산정이 어려울 수 있으므로, 사업장 외 근로에 대한 포괄임금계약의 유효성이 인정될 수 있다. 예를 들어, 기본임금을 미리 산정하지 않고 실제 근로시간과 관계없이 총주행거리에 비례하여 각종 수당을 산정하며, 위와 같이 산정된 각종 수당은 근로기준법이 정하고 있는 연장근로수당 등을 포함하는 것으로 간주한 경우,<sup>44)</sup> 소속운전사들의 근무시간이 각기 일정하지 아니한 점 등을

39) 임종률, 위의 책(주 18), 495면.

40) 임상민, 위의 논문(주 8), 102면 각주 31).

41) 감시·단속적 근로에 대하여 포괄임금계약의 유효성을 인정한 사례로서 대법원 1983. 10. 25. 선고 83도1050 판결; 대법원 1984. 1. 24. 선고 83도2068 판결; 대법원 1993. 5. 27. 선고 92다33398 판결; 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결; 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결.

42) 근로감독관집무규정 제68조 제1항 제1호, 제2호.

43) 대법원 1997. 7. 22. 선고 96다38995 판결.

44) 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결.



감안하여 임금협정을 한 경우,<sup>45)</sup> 추레라 운전업무의 특수성에 비추어 근로시간 수가 일정하지 아니하고 실제 근로시간 수를 사용자가 정확히 파악할 수 없는 경우<sup>46)</sup> 등이다.

그러나, 비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일 근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우에는 포괄임금제에 해당하지 않는다. 그리고 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장근로시간에 대한 합의가 있거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선불리 단정할 수는 없다.<sup>47)</sup>

③ 이른바 일당도급제의 경우에도 포괄임금 방식의 임금 지급계약의 유효할 수 있다. 예를 들어 택시운전사들과 같이 운전사의 총수입금 중 사납금을 공제한 나머지 수입을 운전사 개인의 수입으로 하는 경우 여기의 운전사 개인의 수입에는 근로기준법 소정의 제수당이 포함되어 있다고 보아야 한다.<sup>48)</sup> 또한 일용직급 청소부로 근무해 온 사람의 임금이 일당으로 지급되어 왔음이 분명한 경우 그 일당에는 근로에 대한 통상임금 외의 휴일근무수당, 휴가수당 등 모든 수당도 포함된 것으로 보아야 할 것이다<sup>49)</sup>. 그 외에 한국방송공사와 외부제작요원 사이에 체결된 포괄임금계약의 사례에서는 한국방송공사와 외부제작요원 사이에 09:00부터 21:00까지의 근로에 대하여 시간외수당을 포함한 포괄임금계약이 체결되었다고 볼 수 있더라도 21:00부터 09:00까지의 근무에 대하여는 실제 근무일수에 비례하여 별도의 수당을 지급하고 있었다면 이 부분에 대한 임금지급 방식을 포괄임금제로 볼 수는 없다고 판단하였다.<sup>50)</sup>

④ 사업장 내에서 근로를 제공하는 경우에도 포괄임금 방식의 임금 지

45) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카6934 판결.

46) 대법원 1982. 12. 28. 선고 80다3120 판결.

47) 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579(본소), 2015다233586(반소) 판결.

48) 대법원 1985. 3. 26. 선고 84도1861 판결; 대법원 1988. 3. 22. 선고 87다카570 판결.

49) 대법원 1987. 6. 9. 선고 85다카2473 판결.

50) 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다66995,67004 판결.

급계약을 체결할 수 있다. 예를 들어 염전회사의 직원보수규정이 월 20일 이상의 근무실적이 있는 자에 대하여는 시간외, 야간, 휴일근무의 수당조로 직급별 금액을 정하여 ‘근무수당’이란 이름으로 고정급으로 지급하고 위 근무실적에 미달한 직원에게는 일할계산으로, 또는 시간에 따른 일정비율로 이를 계산하도록 되어 있는 경우,<sup>51)</sup> 매일매일의 기상조건과 현장공사여건 등에 맞추어 공사를 진행하기 때문에 근무시간을 정확하게 확인하는 것이 어려운 해외 건설현장 관리직으로 근무한 경우,<sup>52)</sup> 제분회사의 공장에서 상하차작업을 수행한 경우<sup>53)</sup> 등에서 포괄임금 방식의 임금 지급계약의 유효성이 인정되었다.

## (2) 근로자에게 불이익이 없고, 제반 사정에 비추어 정당할 것

‘근로시간 수의 산정이 어려운 경우’라 하더라도 근로자에게 불이익이 없고, 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 수 있는 경우에 한하여 포괄임금계약이 유효할 수 있다.<sup>54)</sup> 이때 포괄임금제 방식에 의한 임금 지급이 근로자에게 불이익이 없고 정당하다고 인정될 수 있는 것은 근무형태의 특성 그 자체 때문만은 아니고, 포괄임금제의 임금체계에 의하여 임금이 지급되었다고 하더라도 그 지급된 임금에는 법정의 제수당이 미리 포함되어 있다는 사실에 기인하는 것이다.<sup>55)</sup>

① 포괄임금제에 의한 임금 지급계약이 ‘근로자에게 불이익이 없어야 한다’는 것은 단체협약이나 취업규칙에 구체적인 임금지급 기준 등이 규정되어 있는 경우에 그러한 규정상의 기준에 비추어 보아 불이익하지 않아야 한다는 것을 의미한다. 예를 들어 일용직 근로자들에게 지급된 임금이 취업규칙에 비추어 불이익한지 여부는 그 임금액이 일용직 근로자들에게 적용되는 해당 근로계약서의 내용에 비추어 불이익한지의 여부에 의하여 판단하여야 하고 일반 사원들의 임금과의 비교가 반드시 필요한 것은 아니다.<sup>56)</sup>

51) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카15939 판결.

52) 대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결.

53) 대법원 1992. 2. 28. 선고 91다30828 판결.

54) 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다66995,67004 판결; 대법원 2014. 6. 26. 선고 2011도12114 판결.

55) 대법원 1992. 7. 14. 선고 91다37256 판결.

무엇보다 ‘근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우’에 포괄임금에 포함된 정액의 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 때에는 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금 지급계약 부분은 근로자에게 ‘불이익’하여 무효이다.<sup>57)</sup> 즉 근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우라면 포괄임금계약이 근로자에게 불이익한지 여부가 ‘근로기준법이 정한 기준’에 의하여 판단될 수 있을 것이다.<sup>58)</sup>

② ‘제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 수 있어야 한다’는 것은, 단체협약, 취업규칙, 동일 노동동일 임금의 원칙 외의 요소들, 예를 들어 포괄임금제 이전의 연장근로수당 등의 지급 실태, 동종 업계 근로자의 임금 수준 등 기타 사정을 고려하여 정당해야 한다는 취지를 말한다.<sup>59)</sup>

### (3) 기타 포괄임금약정의 유효성 관련 판결

#### 가) 각 수당에 대한 개별적 판단

대상판결에서 언급되고 있지 않지만, 포괄임금약정이 각 수당별로 판단될 수 있는지 문제될 수 있다. 판례는 고속버스 운전기사들이 버스회사를 상대로 포괄임금제의 유효성을 다투며 미지급된 각종 수당의 차액을 청구한 사건에서,<sup>60)</sup> ① 연장근로수당·야간근로수당에 대해서는 버스운송사업의 특수한 근무내용, 근무형태, 근무시간 등을 고려하여 포괄임금제의 유효성을 인정한 반면, ② 휴일근로수당에 관해서는 임금협정 및 그 체계 등을 고려하였을 때 포괄임금약정이 성립하였다고 볼 수 없다고 판단하였다. 동 판결은 포괄임금약정이 유효한지 여부는 각 수당별로 각각 판단할 수 있다는 점을 분명히 하였다.

56) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결.

57) 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결; 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다91046 판결; 대법원 2016. 9. 8. 선고 2014도8873 판결; 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 233586 판결; 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결; 대법원 2022. 2. 10. 선고 2018다298904 판결; 대법원 2023. 11. 30. 선고 2019다29778 판결 등.

58) 노동법실무연구회, 『근로기준법주해 III』 (제2판), 박영사, 2020, 292면.

59) 위의 책, 294면. ‘제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 수 있어야 한다’의 의미에 관한 다양한 견해를 소개하는 송명호, 위의 논문(주 30), 82면 각주 126).

60) 대법원 2022. 2. 11. 선고 2017다238004 판결.

## 나) 사무·연구직에 대한 포괄임금약정의 유효성

사무·연구직에 대한 포괄임금계약의 유효성이 문제된 사례에서, 비록 하급심이기는 하나 법원은 그 약정의 유효성을 부정했다.<sup>61)</sup> 그 판단근거로서, ① 단체협약, 취업규칙, 급여규정 등에 시간외 근로수당에 관한 포괄임금제 합의가 존재한다고 볼 만한 명시적인 규정이 없는 점, ② 오히려 단체협약은 통상임금에 일정 가산율을 적용하여 산정한 금액을 시간외 근로수당으로 정하고 있는 점, ③ 원고들의 근로형태나 업무형태에 비추어 볼 때 근로시간 산정이 어렵지 않은 점, ④ 근로자별 연장근로시간도 일정하지 아니한 점, ⑤ 피고 주장과 같이 기본급에 시간외 근로수당을 포함하여 지급할 수 있도록 하는 근거규정은 전혀 없는 점 등이 고려되었다.

여기에서 동 판결을 이해함에 있어서는 주의가 요구된다고 하겠다. 즉 사무·연구직에 대한 포괄임금약정의 유효성 판단이 단지 근로형태나 업무형태에 비추어 근로시간 산정이 어렵지 않다는 점에만 근거하지 않는다는 것이다. 다시 말해서 사무·연구직의 근로형태나 업무형태에 비추어 근로시간 수의 산정이 어렵지 않더라도 이로써 곧 그에 대한 포괄임금약정이 무효로 되는 것은 아니다. 포괄임금계약(당사자의 합의)이 단체협약, 취업규칙이나 근로계약에 존재하고, 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당을 충족하여 근로자에게 불이익이 없다면, 그러한 포괄임금약정 자체는 유효하다고 할 것이다.

## 3) 근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우

대상판결은 근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 경우 ‘근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정’이 없는 한 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 한다고 판시했다. 그러나 정작 ‘근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정’이 무엇을 의미하는지 제시하지 않고 있다. 현재 그에 관한 판례도 존재하지 않는 것으로 파악된다.

61) 부산고등법원 2021. 1. 21. 선고 2020나11097 판결(1심: 창원지방법원 진주지원 2020. 2. 5 선고 2018가합11438 판결). 동 판결은 피고 회사가 상고를 하지 않아 확정되었다.

살피건대, 대상판결 등이 근로시간 수의 산정이 어렵지 않은 사례에서 설시하고 있는 ‘근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정’은 우리 법원이 법률적 판단을 함에 있어 일반적으로 고려하는 이른바 ‘특별한 사정’과 동일한 취지라고 이해된다. 말하자면 혹여라도 현재의 판결 이후에 다른 개별 사건에서 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없는 사정이 존재할 수 있는 가능성을 염두에 두고 현재의 사건에 대하여 판단하고 있다는 점을 적시하는 것이라 여겨진다.

#### 4. 소결

이상으로 포괄임금계약의 유효성 내지 유효요건과 관련하여, 1970년 처음으로 포괄임금계약의 유효성이 인정된 이후 유효요건은 구체화되고 엄격하게 인정되어왔음을 확인할 수 있었다. 결국 오늘날 포괄임금계약의 유효성 판단을 위한 세부 요건은 다음과 같이 정리할 수 있다고 여겨진다.

- ① 근로자의 승낙(=당사자의 합의)
- ② 단체협약이나 취업규칙 등에 비추어 + 근로자에게 불이익이 없을 것
- ③ 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 것
- ④ 근로시간 및 근로형태와 그 업무의 성질 등을 참작(=근로형태의 특수성)
- ⑤ 연장근로와 야간, 휴일근무가 당연히 예상되는 근로일 경우 인정 가능
- ⑥ 근로시간 산정이 어려운 경우
- ⑦ 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우 ‘근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정’이 존재할 것
- ⑧ 근로시간 산정이 어려운 경우이든 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우이든, ‘임금지급 계약의 내용’에 비추어 근로자가 고정시간외수당(고정OT) 외에 그 기준시간을 초과하는 연장근로에 대하여 ‘초과 연장근로수당’을 청구할 수 없다고 인정될 것

### IV. 포괄임금계약에 관한 개정안 및 해외사례

#### 1. 서(序)

포괄임금계약의 유효요건에 대한 판례의 변화추이를 통해서 확인할 수 있는 것은, 포괄임금계약의 유효성 판단이 지속적으로 보다 엄격화되어 왔다는 점이다.<sup>62)</sup> 그리고 2025. 4. 14. 현재 제22대 국회에는 포괄임금계약을 금지하는 5개의 근로기준법 일부개정법률안<sup>63)</sup>이 제출되어 있다. 말하자면, 대법원 판례가 -그 부정적·비판적 측면에도 불구하고- 여전히 엄격한 요건하에서 포괄임금계약을 인정하고 있는 반면, 위 개정안들은 포괄임금계약(정액급제, 정액수당제)을 전면적으로 금지하고 있는 것이다. 이러한 개정안들에 대해서는 의구심을 갖게 된다. 한편 포괄임금제 방식의 임금지급으로 이해되는 사례는 해외에서도 발견되며, 이들에게 있어서도 -조금씩 차이를 보이지만- 우리 대법원 판례와 같이 포괄임금계약 자체를 전면적으로 금지하지는 않는 것으로 파악된다. 이하에서는 우선 개정안의 내용을 살펴보고, 해외사례에 대하여 간략하게 정리해 본다.

## 2. 개정안 검토

포괄임금계약을 금지하는 개정안들의 내용은 크게 ‘포괄임금계약의 원칙적 금지와 그 유형’ 및 ‘근로시간 관리를 위한 규제 방안’으로 구성되는 것으로 파악된다.

### 1) 포괄임금계약의 원칙적 금지와 그 유형

개정안들은 일관하여 포괄임금계약을 금지하고 있으며, 그 유형으로서 ‘정액급제’와 ‘정액수당제’를 규정한다.<sup>64)</sup> 개정안들에 따르면, 정액급제는

62) 이러한 점을 반영하듯, 정부는 포괄임금제를 규제하기 위한 방안으로서, 2017. 10. 경 ‘포괄임금제 사업장 지도지침(안)’을 마련하여 발표하고자 했으며(실제로 발표되지는 않았다), 현재 포괄임금제 오남용 의심 사업장을 파악하여 별도의 기획·감독을 실시하고, 온라인상에 포괄임금·고정OT 오남용 익명신고센터를 개설·운영하고 있다[고용노동부 노동포털 <https://labor.moel.go.kr/reportCntr/inclusiveWage.do> (2025. 4. 14. 최종방문)].

63) 의안번호 2200760(박해철 의원 대표 발의안), 의안번호 2202812(박홍배 의원 대표 발의안), 의안번호 2203885(박주민 의원 대표 발의안), 의안번호 2205236(이용우 의원 대표 발의안), 의안번호 2205237(정혜경 의원 대표 발의안) 등.

64) 이 점에서 개정안들이 대법원 판례가 일정한 요건하에 정액급제와 정액수당제를 인정하는 것과 대조를 이룬다는 것은 앞서 언급한 바와 같다.

“기본급(임금총액에서 연장·야간 및 휴일근로 등에 따라 가산되는 임금 등을 제외한 금액을 말한다. 이하 같다)을 미리 산정하지 아니하고 제56조에 따른 연장·야간 및 휴일근로에 따라 지급되는 금액을 포함한 임금을 지급하는 내용의 계약”과 “제60조에 따른 연차 유급휴가를 사용하지 아니한 데 따른 보상금액을 포함하여 임금으로 지급하는 내용의 계약”을 말한다.<sup>65)</sup> 그리고 정액수당제는 “기본급을 미리 산정하면서도 제56조에 따른 연장·야간 및 휴일근로에 따라 가산되는 금액을 각 항목별로 구분하지 않고 일정액의 임금을 지급하는 내용의 계약”을 말한다. 양자 모두 정액급제와 정액수당제에 관한 판례의 정의(定義)를 충실히 반영한 결과로 이해된다.

여기에서 포괄임금계약의 유형과 관련하여 주목되는 점은, 개정안들이 금지되는 포괄임금계약으로서 ‘정액급제’와 ‘정액수당제’만을 규정할 뿐, 이른바 ‘고정OT’를 금지하는 개정안은 존재하지 않는다는 점이다. 판례에 따르면, 전자에서는 근로자가 고정시간외수당(고정OT) 외에 그 기준시간을 초과하는 연장근로에 대하여 ‘초과 연장근로수당’을 청구할 수 없는 반면,<sup>66)</sup> 후자에서 근로자는 고정시간외수당(고정OT) 외에 그 기준시간을 초과하는 연장근로에 대하여 여전히 ‘초과 연장근로수당’을 청구할 수 있다는 점에서 차이를 보인다.

[표 2] ‘정액급제 및 정액수당제’와 ‘고정OT’의 구분

| 유형    | 내용                                    | 예시(단위: 만 원)               | 추가지급의무                                                   |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 정액급제  | 기본임금과 법정수당을 구분하지 않음                   | 임금 300 (연장, 야간, 휴일 포함)    | 포괄임금 약정의 효력이,                                            |
| 정액수당제 | 기본임금과 법정수당을 구분하되, 개별수당 간의 금액을 구분하지 않음 | 기본임금 210<br>+ 수당 90 = 300 | - 유효한 경우 추가 지급의무 없음<br>- 무효인 경우 실근로시간에 따라 초과분 추가 지급<br>要 |

65) 한편 의안번호 2200760(박해철 의원 대표 발의안)에서는, 포괄임금계약을 금지하는 것은 다른 개정안들과 동일하나 정액급제와 정액수당제에 관한 정의 규정을 별도로 두고 있지는 않다.

66) 바꾸어 말하면, 이러한 표지는 정액급제와 정액수당제가 포괄임금계약으로서 유효하기 위한 요건이라는 의미이다.

|      |                                                |                                                                                                                                                 |                                  |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 고정OT | 기본임금과 법정수당을 구분하되, 법정수당 모두 또는 일부를 각 수당별 정액으로 지급 | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기본임금 210 + 연장 30 + 야간 30 + 휴일 30 = 300</li><li>○ 기본임금 210 + 연장 30 = 240 (야간과 휴일은 근로시간에 따라 지급)</li></ul> | 약정된 연장근로시간을 초과하는 경우 그 초과분의 추가 지급 |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

살피건대, ① 고정OT는 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정이 그대로 적용되지 않는다는 측면에서 일견 포괄임금제 방식으로 분류할 수는 있을 것이다. ② 고정OT를 도입하는 취지는 의제 근로시간을 인정하여 근로시간을 효율적으로 관리하되, 그 시간을 초과하는 근로에 대해서는 정당하게 수당을 지급하는 것에 있다고 이해된다. ③ 결국 고정OT의 내용과 포괄임금계약에 관한 모든 개정안에서 알 수 있듯이 ‘고정OT’는 ‘금지되는 포괄임금계약’에 해당하지 않는 것으로 사료된다.<sup>67)</sup>

2) 근로시간 관리를 위한 규제 방안

개정안들의 또 다른 목적은 ‘사용자로 하여금 근로시간을 관리하도록 법적 의무를 부여하는 것’으로, 그 방안은 조금씩 차이를 보일 뿐 대체로 동일하다고 이해된다. 즉 개정안들에 따르면, 사용자는 근로자의 근로시간을 ‘기록<sup>68)</sup> 및 보존<sup>69)</sup>’하고, 근로자가 요구하는 경우 그 기록을 ‘열람<sup>70)</sup> 및 교부<sup>71)</sup>’해야 하며, 그 산정 결과를 고용노동부장관에게 ‘제출’<sup>72)</sup> 또는 ‘신

67) 이러한 이유에서 ‘고정OT’를 직접적으로 다루는 판결례는 잘 보이지 않는다고 여겨진다. 고정OT에 관한 판결례로서 부산고등법원 2024. 6. 13. 선고 2023나56333 판결(1심 판결: 부산지방법원 2023. 8. 24. 선고 2021가합43404 판결), 서울중앙지방법원 2023. 4. 11. 선고 2022나2420 판결 등 참조.

68) 의안번호 2200760(박해철 의원 대표 발의안), 의안번호 2202812(박홍배 의원 대표 발의안), 의안번호 2203885(박주민 의원 대표 발의안), 의안번호 2205236(이용우 의원 대표 발의안), 의안번호 2205237(정혜경 의원 대표 발의안).

69) 의안번호 2205236(이용우 의원 대표 발의안), 의안번호 2205237(정혜경 의원 대표 발의안).

70) 의안번호 2203885(박주민 의원 대표 발의안).

71) 의안번호 2202812(박홍배 의원 대표 발의안), 의안번호 2205236(이용우 의원 대표



고<sup>73)</sup>하여야 하고, 근로자는 작성된 근로시간 측정기록의 등사<sup>74)</sup>를 청구할 수 있다.

### 3. 해외사례 검토

#### 1) 일본

##### (1) 포괄임금제 유효요건

일본의 경우 포괄임금제에 대하여 엄격하게 규제하고 있다.<sup>75)</sup> 일본의 판례·통설에 따르면, ① 기본급 가운데 시간외근로수당에 대한 부분이 분명하게 구분되어 그 부분이 연장근로수당에 해당한다는 점에 관한 합의가 존재하고, ② 노동기준법에서 규정하는 임금계산방식에 따라 산정한 임금액이 당사자 간의 합의에 따라 산정한 임금액보다 높은 경우 그 차액에 대한 추가 지급 청구를 인정한다는 합의가 존재하는 경우, 포괄임금약정은 유효하다.

##### (2) 정액급제와 정액수당제의 구별

정액급제에서는 기본급과 법정수당을 구분하지 않는다. 따라서 기본급과 시간외근로수당이 구분되지 않으므로 이러한 포괄임금약정은 무효이다. 반면 정액수당제에서는 기본급과 법정수당을 구분할 수 있다. 따라서 이러한 방식의 포괄임금약정은 유효할 것이다. 만약 포괄임금약정에 따라 산정된 정액수당이 노동기준법에서 규정하는 임금계산방식에 따라 산정된 임금액에 미달하는 경우 그 차액은 추가로 지급되어야 한다.

##### (3) 근로시간 산정의 어려움 요건 요부

---

발의안).

72) 의안번호 2203885(박주민 의원 대표 발의안).

73) 의안번호 2200760(박해철 의원 대표 발의안), 의안번호 2205236(이용우 의원 대표 발의안).

74) 의안번호 2203885(박주민 의원 대표 발의안).

75) 이하 일본의 사례에 관하여 최석환, “일본의 근로시간 제도개혁과 포괄임금제”, *아주법학 제12권 제2호*(아주대학교 법학연구소, 2018), 222-241면.

일본은 -현재 우리의 사례와 달리- 포괄임금약정의 유효요건으로서 ‘근로시간 산정의 어려움’ 요건을 요구하지 않는다. 요컨대 위에서 언급했던 요건① 및 ②이 충족되는 때에는 근로시간 산정의 어려움 여부에 불구하고 차액에 대한 지급 청구가 인정될 수 있다.

## 2) 미국

### (1) 임금체계

미국의 임금체계는 두 가지로 구분될 수 있다.<sup>76)</sup> 하나는 ‘Wage 체계’이고 다른 하나는 ‘Salary 체계’이다.<sup>77)</sup> 전자(Wage)는 대체로 육체노동을 하는 생산직 근로자의 근로시간에 비례하여 ‘시간급’ 형태로 산정된 임금을 일당, 주급, 혹은 월급으로 지급하는 임금형태를 말한다. 반면 후자(Salary)는 -임금을 ‘시간급’으로 계산하는 것이 아니라- 근로계약을 체결 시에 합의한 ‘일정금액’을 주급 또는 월급으로 지급하는 임금형태를 말한다.

### (2) 직원의 구분에 따른 포괄임금제 여부

미국에서 직원은 ‘면제(Exempt) 직원’과 ‘비면제(Non-exempt) 직원’으로 분류된다. 양 자의 가장 큰 차이점은 OT 수당을 받을 수 있는지 여부이다. ‘면제 직원’에게는 통상 정해진 연봉(Salary)이 지급되며, 따라서 OT 수당이 적용되지 않는다. 반면, ‘비면제 직원’에게는 공정근로기준법(Fair Labor Standards Act)에 의하여 OT 수당에 대한 지급 청구권이 인정된다. ‘면제 직원’에게 인정되는 연봉(Salary)이 이른바 진정한 의무의 ‘포괄임금제’라고 평가된다.

## 3) 영국

### (1) 최장 근로시간 적용의 배제

<sup>76)</sup> 이하 미국의 사례에 관하여 김성권, 『채용에서 퇴직까지 -인사노무관리 매뉴얼 및 해설-』, 삼원사, 2019.

<sup>77)</sup> ‘wage’와 ‘salary’ 모두 우리말로 ‘급여’를 나타내므로 둘을 구분하기 위해 원문을 그대로 인용한다. 이하 같다.

영국에서 1주 최장 근로시간은 48시간이다.<sup>78)</sup> 그러나 영국의 근로시간 시행령은 노무제공자의 동의를 전제로 1주 최장 근로시간의 적용을 배제할 수 있는 ‘옵트아웃(Opt-out)’을 인정하고 있다. 이를 통해서 1주 최장 48시간을 초과하는 근로가 허용될 수 있는 것이다.

영국의 ‘옵트아웃’에 대해서는 유럽연합 근로시간지침<sup>79)</sup>의 근본 목적을 훼손한다는 비판이 가해진다. 유럽연합 근로시간지침의 목적은 근로자의 건강과 안전 증진이고, 이를 관철하기 위해서는 무엇보다 근로시간의 제한이 가장 중요하게 준수되어야 하기 때문이다.

## 2) 옵트아웃의 유효요건

옵트아웃은 만 18세 이상의 근로자에게 적용된다. 유효요건으로서 당해 근로자의 자발적 서면동의, 옵트아웃 시행 기간 동안 근로시간 의무 기록, 근로자의 임의 취소 가능성 보장 등이다.

## 4) 프랑스

### (1) 임금 포괄약정

프랑스는 노동법전(Code du travail) 제3부 제1권 제2편 제1장 제5절에서 근로시간 및 임금 포괄약정제(convention de forfait, 이하 ‘포괄약정’이라 함)에 관하여 규정하고 있다.<sup>80)</sup> 이로써 연간 근로일수와 임금을 포괄적으로 약정하는 경우 근로시간 규정의 적용이 배제될 수 있다. 포괄약정에는 ‘주, 월 또는 연간 근로시간수약정(forfait en heures)’과 ‘연간 근로일수약정(forfait en jours)’의 2가지가 있다.

## 2) 요건

<sup>78)</sup> 이하 영국의 사례에 관하여 남궁준·김근주·구미영, 『영국 근로시간법제의 변천과 정책적 시사점』, 정책연구 2019-16, 한국노동연구원, 2019.

<sup>79)</sup> Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time.

<sup>80)</sup> 이하 프랑스의 사례에 관하여 조용만, “프랑스 근로시간법제에서 근로시간의 유연화와 근로자 보호”, 서울법학 26권 3호(서울시립대학교 법학연구소, 2018), 517-552면.

동 규정이 모든 근로자에게 적용되는 것은 아니다. 즉 ① 근로시간의 배분과 사용에 대하여 재량을 갖는 관리직 근로자 및 ② 근로시간이 사전에 결정될 수 없고 부여된 업무수행을 위해 근로시간에 대하여 재량을 갖는 근로자에게 적용된다.

당사자 간에는 적용기간, 연간 근로시간수(예: 주 39시간 또는 월 169시간) 내지 연간 근로일수(예: 연간 218일), 적용 기간 중 휴가·휴직·퇴직 시 임금의 계산 방법 등 7가지에 관하여 단체협약을 통한 합의가 요구된다.

#### 4. 소결

이상으로 포괄임금계약에 관한 개정안 및 해외사례에 관하여 개략적으로 정리해 보았다. 우리 개정안들이 정액급제와 정액수당제의 포괄임금계약을 원칙적으로 금지하는 것과 비교하여, 해외사례에서 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다고 여겨진다.

① 일본의 경우, 정액급제 방식의 포괄임금계약이 인정되지 않는 반면, - 우리와 같이- 정액수당제 방식의 포괄임금계약은 인정된다. 다만 우리 판례에서 중핵적 판단기준으로 작동하는 ‘근로시간 사정의 어려움’ 요건은 요구하지 않고 있다.

② 미국의 경우, 면제 직원에게 지급되는 연봉(Salary)이 포괄임금에 해당하는 것으로 이해된다. 다만 우리의 경우 생산직 근로자와 사무직 근로자를 구분하지 않고 포괄임금계약이 인정될 수 있는 반면, 미국의 경우 생산직 근로자에 대해서는 포괄임금계약이 인정되지 않는다는 점에서 차이가 있다.

③ 영국의 경우, 윗트아웃에 의한 1주 최장 48시간을 초과하는 근로가 허용될 수 있다는 점에서, 포괄임금제에 의하더라도 원칙적으로 1주 최장 52시간을 초과할 수 없는 우리와 구별된다. 우리 법제에서 포괄임금제가 장시간 근로를 고착화하여 근로자의 일과 삶의 균형을 훼손하고 공짜 노동을 조장할 수 있다는 비판은, 아마도 영국의 윗트아웃에 따른 초과근로에도 가능하다고 여겨진다.

④ 프랑스의 경우, 우리 법제와 다르게 근로시간 및 임금 포괄약정을 노동법전에서 명문으로 규정하고 있다는 점은 포괄임금계약에 대한 개정안을

마련하고 있는 우리에게 시사하는 바가 적지 않다고 생각한다. 우리의 모든 개정안들이 포괄임금계약을 원칙적으로 금지할 뿐, 허용하는 개정안은 없기 때문이다.

## V. 나오며

지금까지 포괄임금계약의 유효요건에 관하여 대법원 판례의 변화추이를 중심으로 살펴보았다. 포괄임금계약의 유효성은 법원이 ‘대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결’을 통해서 처음으로 인정한 이후 현재까지도 유지되고 있다. 다만 판례는 포괄임금계약의 유효요건에 관하여 지속적으로 보다 엄격하게 요구해 왔음을 알 수 있다. 그리고 허용 또는 금지되는 포괄임금계약의 유형은 ‘정액급제’와 ‘정액수당제’이며, ‘고정OT’는 -결론적으로- 그러한 포괄임금계약에는 해당하지 않는다고 판단된다.

대법원 판례와 다르게, 현재 제22대 국회에 제출되어 있는 5개의 포괄임금계약에 관한 근로기준법 일부개정법률안은 동일하게 포괄임금계약을 금지하고 있다. 반면 해외사례는 -조금씩 차이를 보이기는 하지만- 포괄임금계약 자체를 원칙적으로 금지하지는 않는 것으로 파악된다. 특히 프랑스는 근로시간 및 임금 포괄약정을 노동법전에서 명문으로 규정하고 있다는 점에서 우리 개정안들과 분명한 차이를 보인다.

요컨대 대법원 판례가 오늘날에도 여전히 인정하고 있는 포괄임금계약을 -개정안과 같이- 전면적으로 금지하는 것만이 정당한 것인지에 대해서는 의문이 있다. 물론 최근의 판례에서는 마치 포괄임금계약의 유효성을 부정하는 경향이 강화되는 것처럼 보이기도 한다. 그럼에도 법원이 오늘날까지 포괄임금계약의 부정적이고 비판적인 측면들을 소각하기 위해 그 유효요건에 대하여 지속적으로 엄격하게 판단해 왔던 점, 무엇보다 그와 같은 엄격한 요건과 판단기준에 따라 결과적으로 근로자의 정당한 임금이 보전될 수 있도록 제도가 운영될 수 있다는 점,<sup>81)</sup> 나아가 해외사례를 보더라도 포괄임금계약의 전면적인 금지만이 문제 해결의 유일한 방안으로 보이

81) 제도의 존재와 그 운영은 분리될 수 있다고 여겨진다.

지 않는다는 점을 고려할 때, 개정안의 내용들은 보다 더 면밀한 검토가 필요하다고 사료된다.

## 참고문헌

### <국내문헌>

#### ○ 단행본

- 김성권, 『채용에서 퇴직까지 -인사노무관리 매뉴얼 및 해설-』, 삼원사, 2019.
- 남궁준·김근주·구미영, 『영국 근로시간법제의 변천과 정책적 시사점』, 정책연구 2019-16, 한국노동연구원, 2019.
- 노동법실무연구회, 『근로기준법주해 III』(제2판), 박영사, 2020.
- 임종률, 『노동법』(제20판), 박영사, 2022.

#### ○ 논문

- 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토”, 노동법연구 26호(서울대학교 노동법연구회, 2008).
- 김기선, “26. 포괄임금제의 성립요건과 효력”, (노동관례백선, 2021).
- 김홍석, “포괄임금제에 관한 법적 성격과 쟁점”, 법학연구 34권 2호(충남대 법학연구소, 2023).
- 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토”, 성균관법학 23권 3호(성균관대학교 법학연구원, 2011).
- 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰”, 인권과 정의 347호(대한변호사협회, 2005).
- 심재진, “포괄임금제의 쟁점과 전망”, 노동법학 64호(한국노동법학회, 2017).
- 이광선, “포괄임금 약정의 효력과 문제점”, 저스티스 141호(한국법학원, 2014).
- 임상민, “포괄임금제의 성립 및 유효요건”, 인권과 정의 502호(대한변호사협회, 2021).
- 정재현, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, (한국노동연구원, 2016).
- 조용만, “프랑스 근로시간법제에서 근로시간의 유연화와 근로자 보호”, 서울법학 26권 3호(서울시립대학교 법학연구소, 2018).

조임영, “포괄임금제에 의한 임금 지급계약의 성립요건”, 노동법률 95호(중앙경제사, 1999).

최석환, “일본의 근로시간 제도개혁과 포괄임금제”, 아주법학 제12권 제2호(아주대학교 법학연구소, 2018).

하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계”, 노동법학 29호(한국노동법학회, 2009).



<Abstract>

A Study on the Validity Condition of Blanket Wage Contract  
-Focusing on Developments in Supreme Court case law-

Sung, Daegyul\*

A blanket wage contract is not a system prescribed by the Labour Relations Act. The validity of blanket wage contract was first recognised by the Supreme Court in its decision of 28 May 1974 (73Da1258) and has been developed by case law since then. However, the blanket wage contract has been the subject of constant criticism. Case law has also taken a stricter and more restrictive approach to the validity of blanket wage contract.

The case law has recognised the validity of a flat-rate payment system and a flat-rate allowance system. The validity of a blanket wage contract requires the parties' agreement as a prerequisite. Recent precedents focus on the 'difficulty in calculating working hours' as a key criterion. Contrary to case law, the proposed amendments to the Labour Standards Act would ban blanket wage contract. The wage payment practices or systems that are understood to be comprehensive wage systems have been operating overseas.

In short, it is questionable whether blanket wage contract should be banned outright, such as the proposed amendment, for the following reasons: ① the Supreme Court has been very strict on the validity of blanket wage agreements; ② the strict judgement of the courts ensures that the system is operated in such a way that the rightful wages of the workers are preserved as a result; ③ a comprehensive wage system have been recognised to a limited extent in major foreign countries. In

---

\* Assistant Professor at Kangwon National University Law School, Ph.D. in Law.

light of these considerations, an outright ban on blanket wage contract does not seem to be the only way to solve the problem. Therefore the proposed amendments to the Act need to be further scrutinised.

Keywords : validity of blanket wage contract, flat-rate payment system, flat-rate allowance system, agreement of the parties, difficulties in calculating working hours